

1500394-50.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Estatuto do Desarmamento. Sanções do tráfico intocadas. Regimes preservados. PROVIMENTO PARCIAL. Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Tatuí. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Data de publicação: 05/11/2020.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500394-50.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302166/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21234270 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6345/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2302166 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILIAM CESAR CICCACI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

WILIAM CÉSAR CICCACI, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" c.c o artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Notificado (fls. 310), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 346/349.

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 371/372).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o acusado foi interrogado (fls. 496 e 531).

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a parcial

procedência da ação penal, com absolvição do réu pelo crime de associação e condenação pela prática de tráfico de drogas.

A defesa arguiu a nulidade da diligência de busca e apreensão que ensejou a prisão do acusado. No mérito, postulou a absolvição do réu ou, de maneira subsidiária, a aplicação das benesses legais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, não merece guarida a arguição defensiva de nulidade processual.

Não há vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades sobre fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão às práticas ilícitas. Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate aos crimes. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subseqüentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foi a simples denúncia que acarretou a prisão do réu. Elas deram início às investigações preliminares empreendidas pelos policiais civis, deram azo à expedição de mandado de busca e apreensão, ensejando o encontro das drogas e a confirmação das informações recebidas acerca do armazenamento de substâncias ilícitas praticado pelo acusado, que, no mais, foi por ele confessado sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (USO PERMITIDO). Recurso defensivo. PRELIMINAR. Alegação de suposta nulidade do início de investigação por “denúncia anônima” que se confunde com a questão de fundo. MÉRITO. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Acervo probatório robusto. Condutas típicas. Prisão flagrante que se deu pela certeza visual do delito e não por delação anônima. DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado unicamente às iniciais do delito do Estatuto do Desarmamento. Sanções do tráfico intocadas. Regimes preservados. PROVIMENTO PARCIAL. Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Tatuí. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Data de publicação: 05/11/2020.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/8 e 9), boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 27/28), fotografias (fls. 41/59), laudos periciais (fls. 172/187 e 188/197), além da prova oral.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que estava guardando drogas para Wellington (Tico) e disse que assim agiu porque, no mesmo dia de sua prisão, ele esteve em sua residência e o ameaçou para que guardasse os entorpecentes até o final do dia para quitar uma dívida de drogas que havia contraído em conjunto com seu patrão (R\$100,00). Quando os policiais estiveram em sua residência, apontou o local onde a droga havia sido escondida. O advogado que esteve na delegacia foi enviado por Wellington e lhe pediu para que assumisse a propriedade da droga, todavia se negou a alterar a versão apresentada. Na época dos fatos, trabalhava como marceneiro para

Leandro e residia com ele no local dos fatos durante a semana. Negou já ter guardado drogas para Tico anteriormente e, após visualizar as imagens de fls. 27/28, efetuou o reconhecimento de Wellington do Couto.

A testemunha Humberto narrou que residia na casa onde foi cumprida a busca e que não conhece "Tico", malgrado os agentes perguntassem por ele e pelas drogas. Tanto o dinheiro quanto os dois celulares apreendidos lhe pertenciam. Negou já ter comprado drogas de Tico, em que pese seja usuário de drogas. Conhecia os policiais envolvidos de uma ação policial, na qual foi preso pelo roubo de um carro cerca de quatro anos antes.

O policial civil Osvaldo informou já ter participado de operações anteriores envolvendo Tico, mas não conhecia William. Na data da diligência, esteve na casa de Tico, onde ouviu barulhos que indicavam fuga pelos fundos do imóvel. Dentro da casa havia uma pessoa (Humberto), que informou prestar pequenos serviços a Tico em troca de drogas. A droga apreendida foi encontrada na casa de William (onde funcionava uma oficina de marcenaria), onde ele foi abordado juntamente com outra pessoa. Na ocasião, William alegou ter sido ameaçado por Tico naquele dia para que armazenasse as drogas, por conta de uma dívida.

O policial civil Paulo confirmou, em linhas gerais, a narrativa ofertada por seu colega e acrescentou ter recebido denúncias do local onde um indivíduo estava armazenando drogas para Tico. Apesar das referidas denúncias não qualificarem William, as características pessoais informadas eram compatíveis com as dele. As denúncias também apontavam que o imóvel localizado na Rua Benedito Manoel, 269 era a residência de Tico. Antes do cumprimento da diligência, promoveu campanhas e, quando visualizou William sair com Leandro do imóvel, promoveu a abordagem. As drogas apreendidas estavam dentro de uma bolsa, que pertencia a William.

Pois bem. Como se vê, as provas são suficientes apenas para a segura comprovação do crime de tráfico atribuído ao réu.

O réu admitiu o tráfico sob o crivo do contraditório o armazenamento dos entorpecentes, alegando ter sido ameaçado por Wellington do Couto por conta de uma dívida de drogas com ele. No mesmo sentido, as narrativas apresentadas pelos policiais civis, que apreenderam significativa quantidade e variedade de entorpecentes na posse do acusado, incompatíveis com o mero consumo próprio.

Nada há nos autos a afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis colhidos durante a instrução.

A justificativa do réu para a prática do delito não o beneficia. Além de não haver prova de coação irresistível (até porque a conduta do réu acarretaria a vantagem de quitar a dívida), teria sido o próprio acusado quem se colocou na situação narrada - aquisição de entorpecentes - voluntariamente. Por isso, não poderia se beneficiar de uma situação para a qual ele mesmo concorreu originalmente. No mais, ele é apto para o trabalho e poderia ter buscado meios lícitos para saldar o valor devido dentro do prazo acordado.

Em adição, o fato de o réu não comercializar o entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida

de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

E, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, isso não exclui a possibilidade de que o venda ou, armazene para terceiros, posto que tais condutas frequentemente coexistem, até mesmo para sustento do consumo. Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.).”

Noutra ponta, embora haja indícios do delito de associação, notadamente face às investigações que precederam a expedição do mandado de busca, remanesce dúvida quanto a tal delito, conforme esposado pelo próprio titular da ação penal.

Desta feita, de rigor a parcial procedência da ação para condenar o réu apenas pelo crime de tráfico de entorpecentes

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendida, sendo parte dela (“crack”) de alta potencialidade lesiva. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, assim como a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”), além da reincidência (por quatro condenações), que é, inclusive, específica (fls. 419/420 - Proc. 0000272-91.2017.8.26.0165, fls. 420/421 - Proc. 0000960-34.2009.8.26.0165, fls. 423/424 - Proc. 0003032-62.2007.8.26.0165 e fls. 426/427 - Proc. 0005058-72.2003.8.26.0165). Assim, majoro a reprimenda para 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu e os motivos esposados na primeira fase ensejam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Não há se falar em desproporcionalidade ou “bis in idem” entre o reconhecimento da reincidência na segunda fase e o afastamento da causa de diminuição em comento, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Não

há falar em bis in idem na utilização da reincidência do paciente na segunda fase de fixação da pena - para fins de agravamento da reprimenda -, e na terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a aplicação da causa de redução de pena prevista no art.33, §4º, da Lei no 11.343/06 -, por haver expressa previsão legal para a ponderação dessa mesma circunstância nos dois momentos de fixação da pena, permitindo-se chegar à reprimenda mais adequada e suficiente para a prevenção do delito. 2. Habeas corpus denegado" (STJ - HC 188.699/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DOTJ/CE), SEXTATURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 18/04/2011).

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando o quantum de pena fixado e a reincidência, a reprimenda deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das

Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu WILLIAM CESAR CICCACI, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP, mas para CONDENÁ-LO à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

O réu respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, ressaltando-se, ademais, a reincidência. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA